

0025163-80.2016.8.26.0564

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Apropriação indébita

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... para defender o filho dele, preso por tráfico de droga. Foi combinado o pagamento dos honorários advocatícios para acompanhamento do inquérito policial e da ação criminal. Cumpriu o contrato, mas a vítima não pagou os honorários advocatícios, embora mensalmente cobrada (sem formalização), até que Enrique a procurou para pedir que usasse o montante que seria pago pelo INSS (valor que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

0025163-80.2016.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0025163-80.2016.8.26.0564

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 482/2016 - 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cristiane Leandro de Novais

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

CRISTIANE LEANDRO DE NOVAIS, qualificada nos autos, foi denunciada e processada como incurso nas penas do artigo 168, §1º, inciso III, do Código Penal, porque no dia 30 de novembro de 2015, em horário incerto, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, apropriou-se da quantia de R\$ 28.978,13 (vinte e oito mil,

novecentos e setenta e oito reais, e treze centavos), pertencente à vítima Enrique Eduardo Fernandez Torres, valor de que tinha a detenção em virtude de sua profissão de advogada.

Segundo se apurou, em 20 de julho de 2010, a vítima contratou a advogada CRISTIANE para prestar serviços advocatícios na defesa de ação de auxílio doença convertido em aposentadoria em face do INSS. Na ocasião, ajustou-se que, a título de remuneração, a vítima deveria pagar à acusada o valor dos 03 (três) primeiros benefícios concedidos e mais 30% (trinta por cento) sobre o valor final.

A vítima pagou à acusada, a título dos serviços advocatícios, 01 (uma) parcela de R\$2.450,00, em janeiro de 2011, e 04 (quatro) parcelas mensais de R\$1.131,00, em fevereiro, março, abril e maio de 2011 (cf. págs. 30/32).

A ação foi ajuizada e o processo tramitou de forma regular (autos nº 00077755720084036114 da 1ª Vara de São Bernardo do Campo da Justiça Federal – págs. 89/345), mas após algum tempo a acusada passou a não prestar mais contas da sua atuação no feito, até que a vítima descobriu que a causa já havia sido julgada procedente e que a ré havia se apropriado do valor total do benefício, em prejuízo da vítima, sob a justificativa de que a vítima já vinha recebendo os benefícios e não teria direito a receber a diferença pela revisão.

Segundo consta, a referida ação foi julgada procedente para o fim de condenar o INSS a conceder à vítima o auxílio-doença (NB 123.681.282-1), desde a data da cessação (15/09/2008), devendo o INSS providenciar sua reabilitação, com tutela antecipada; bem como para condenar o INSS ao pagamento das parcelas em atraso, desde a data em que se tornaram devidas, com correção e juros, conforme a r. sentença de págs. 249/255.

O INSS interpôs apelação, mas o recurso não foi provido, em julgamento monocrático no TRF da 3ª Região, transitando em julgado a r. decisão em 12/04/2014 (págs. 291/295).

O INSS apresentou cálculo do que era devido à vítima a título de benefício com correção (R\$27.916,50) e à acusada a título de honorários (R\$2.791,65), de forma discriminada, conforme pág.329. Em petição protocolizada em 15/09/2015, a acusada concordou com o cálculo (pág. 331). Em 27/10/2015, o INSS depositou em conta judicial os valores devidos (págs. 337/338).

Então, em 30/11/2015, sem a ciência e a aquiescência da vítima, a acusada compareceu à agência da Caixa Econômica Federal e sacou os valores depositados pelo INSS, de forma integral, tanto dos honorários advocatícios (págs. 341/342), como dos benefícios devidos à vítima, esses no total de R\$ 28.978,13 (págs. 339/340), deixando de repassá-los à vítima.

A seguir, a vítima não conseguiu mais contato com a acusada e não teve outra solução senão registrar, em 10/06/2016, o boletim de ocorrência de págs. 07/08. Assim agindo, a acusada, após se encontrar na posse dos valores devidos à vítima, em razão de sua profissão de advogada, inverteu seu ânimo e tomou como própria uma importância em dinheiro pertencente à vítima, sem justificativa plausível e em total desacordo com as cláusulas estipuladas no contrato de serviços advocatícios. Registra-se, por fim, que a acusada está envolvida na prática de outros crimes de apropriação indébita e estelionato, conforme BOs de págs. 10/15 e 18/19.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial a págs. 04/81 e foi recebida a págs. 385/387. A ré foi citada (pág. 397) e ofertou reposta à acusação (págs. 399/418). Não reconhecidas as hipóteses de absolvição sumária (págs. 470/471), em instrução foram ouvidas vítima e seis testemunhas de defesa, interrogando-se a ré.

Em memoriais, o Ministério Público requer a condenação da acusada nos termos da denúncia, com elevação da pena base e fixação de regime inicial aberto para início de cumprimento de pena (págs. 715/731).

A defesa pleiteia pugna pela absolvição por atipicidade, ausência de dolo ou, ainda, por insuficiência probatória. Aduz que a ré teria agido no exercício regular de seu direito e, de qualquer forma, a questão deve ser solucionada em âmbito cível apenas.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 345 do Código Penal, afastamento da causa de aumento de pena, fixação da pena no mínimo legal e regime mais benéfico para cumprimento de pena, observando-se os artigos 44 e 77, ambos do Código Penal (págs. 735/771).

É o relatório do essencial.
Fundamento e DECIDO.

Preliminarmente, observa-se que a ré não tem direito à suspensão condicional do processo (benesse requerida pela defesa a pág.767 dos memoriais), não preenchidos os requisitos legais previstos no caput do artigo 89, da Lei nº 9.099/95 (a ré ostenta condenações e processos em andamento pelo mesmo crime).

No mérito, a pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de apropriação indébita qualificada, que se configurou, não havendo dúvida quanto à autoria e dolo.

A materialidade delitativa é inconteste e vem consubstanciada nos recibos juntados às págs. 30/32, bem como nos comprovantes de pagamento de págs. 339/340 e 341/342.

Restou incontroverso nos autos que:

a) A ré foi contratada pela vítima para prestar serviços advocatícios previdenciários. Na ocasião, ajustou-se que, a título de remuneração, a vítima deveria pagar à acusada o valor dos 03 (três) primeiros benefícios concedidos e mais 30% (trinta por cento) sobre o valor final.

b) A vítima pagou à acusada, a título dos serviços advocatícios, 01 (uma) parcela de R\$2.450,00, em janeiro de 2011 (a pág.30 consta que se trata do valor 'referente ao primeiro benefício concedido do INSS), e 04 (quatro) parcelas mensais de R\$1.131,00, em fevereiro, março, abril e maio de 2011 (cf. págs. 31/32, em relação aos dois outros benefícios, subsequentes).

c) Na ação ajuizada (autos nº 00077755720084036114 da 1ª Vara de São Bernardo do Campo da Justiça Federal – págs. 89/345), o pedido foi julgado procedente para o fim de condenar o INSS a conceder à vítima o auxílio-doença (NB 123.681.282-1), desde a data da cessação (15/09/2008), devendo o INSS providenciar sua reabilitação, com tutela antecipada; bem como para condenar o INSS ao pagamento das parcelas em atraso, desde a data em que se tornaram devidas, com correção e juros, conforme a r. sentença de págs. 249/255. Trânsito em julgado em 12/04/2014 (págs. 291/298).

d) O INSS apresentou cálculo do que era devido à vítima a título de benefício com correção (R\$27.916,50) e à acusada a título de honorários (R\$2.791,65), de forma discriminada, conforme pág.329. Em petição protocolizada em 15/09/2015, a acusada concordou com o cálculo (pág. 331). Em 27/10/2015, o INSS depositou em conta judicial os valores devidos (págs. 337/339).

e) No dia 30/11/2015 a acusada compareceu à agência da Caixa Econômica Federal e

sacou os valores depositados pelo INSS, de forma integral, tanto dos honorários advocatícios, como dos benefícios atrasados devidos à vítima (esses no total de R\$ 28.978,13, cf.págs. 339/342).

A controvérsia cinge-se em relação à apropriação indébita praticada pela acusada.

Na inicial acusatória consta que, em 30/11/2015, sem a ciência e a aquiescência da vítima, a acusada, após se encontrar na posse dos valores devidos a Enrique, em razão de sua profissão de advogada, inverteu seu ânimo e tomou como própria importância em dinheiro pertencente ao cliente (referente à diferença a pagar pelo INSS em favor da vítima, após concessão dos benefícios, no valor de R\$ 28.978,13, cf.págs. 339/340), sem justificativa plausível e em total desacordo com as cláusulas estipuladas no contrato de serviços advocatícios.

A ré defende-se alegando que, na realidade, a vítima devia-lhe quantia maior que a de R\$ 28.978,13, em razão dos serviços advocatícios prestados em outros processos, tendo combinado com Enrique que o valor recebido na ação mencionada na denúncia seria usado para pagamento da dívida.

Em Juízo, a acusada declarou que:

O Sr. Enrique foi colega de serviço de seu pai. Conhece-o há 30 anos. Após período sem contato, Enrique a procurou porque era investigado em inquérito policial que tramitava na Polícia Federal acerca de fraude do INSS. Em razão das investigações, peritos e funcionários do INSS de São Bernardo do Campo foram afastados. Acompanhou o tramite do caderno investigatório. O benefício da vítima e de outros investigados havia sido 'cortado'.

Ajuizou ação pedindo tutela antecipada para restabelecer o auxílio-doença. O pedido foi acolhido e a vítima começou a receber os valores previdenciários. Deveria pagar os três primeiros benefícios e mais 30% sobre o valor final a título de honorários.

Em seguida, Enrique a procurou para defender o filho dele, preso por tráfico de droga. Foi combinado o pagamento dos honorários advocatícios para acompanhamento do inquérito policial e da ação criminal. Cumpriu o contrato, mas a vítima não pagou os honorários advocatícios, embora mensalmente cobrada (sem formalização), até que Enrique a procurou para pedir que usasse o montante que seria pago pelo INSS (valor que receberia no processo mencionado na denúncia) para pagamento de todos os serviços advocatícios que tinha prestado (declarou que também tinha ajuizado ação em face da Motorola e da Caixa Econômica Federal, efetuado acompanhamento junto ao Procon, dentre outras atividades inerentes ao serviço advocatício). Aceitou a proposta. Não houve acordo formal, apenas verbal.

Assim, quando levantou o RPV do processo do INSS, informou à vítima que faria a compensação e ainda restaria crédito em seu favor (ré) de 10 a 12 mil reais. A conversa ocorreu por telefone, sem registro (a vítima acompanhava o andamento processual. O e-mail de Enrique era cadastrado no sistema PUSH da Justiça Federal). Confiou na vítima porque o conhecia havia muitos anos. Não teve mais contato com Enrique.

Tais declarações contrariam informação estampada na resposta à acusação, peça processual na qual a ré aduziu que havia formalizado termo de acordo com a vítima (págs.404/405):

“Diante de tantos trabalhos jurídicos realizados, e com pendências em três ações, estabeleceu-se entre as partes que os valores a serem recebidos, nas ações que verteriam em ganho financeiro seriam compensados, ou seja, foram autorizados pelo suposta vítima, que ficariam com a advogada a título dos honorários advocatícios,

sendo que foi feito um termo de acordo na época, sendo que o mesmo fora feito, e, houvera testemunhas, que assinaram sendo que em momento algum, houve apropriação como a suposta vítima tentou induzir todos a erro.
(...)

Assim ficou amplamente demonstrado no termo de acordo, que os valores, a serem recebidos no RPV DO INSS, seriam devidos, após o desconto dos honorários daquele processo, a , título de honorários contratados, das defesas do processo criminal onde foi constituída a denunciada e defesa do processo de seu filho, cujo a suposta vítima a contratou" - grifo nosso.

Para justificar a ausência do documento nos autos a ré ainda acrescentou, na peça de págs.399/418, ter perdido a documentação que provaria seu álibi quando o arquivo de seu escritório, antes localizado na Rua Bela Vista, no Centro de São Bernardo do Campo, foi atingido por uma enchente.

No interrogatório judicial prosseguiu: Quase dois anos depois, Enrique ofertou representação na OAB e registrou o boletim de ocorrência juntado aos autos. Não sabe indicar o motivo.

Sobre os valores dos serviços advocatícios, alegou ter sido combinado, em relação aos procedimentos criminais (acompanhamento do inquérito policial contra a vítima, na Polícia Federal, e defesa em ação penal ajuizada contra o filho), o valor de 15 mil para cada um (na resposta à acusação, a ré informa que cobrou R\$8.000,00 para defender o filho de Enrique, cf, págs.403/404).

O primeiro contrato de prestação de serviços advocatícios, relativo ao inquérito policial que tramitou na Polícia Federal (investigação de fraude contra INSS. Enrique teria sido chamado para prestar declarações), no valor de R\$15.000,00, valia até Primeira Instância, se houvesse processo (a ré aduziu que o documento provando sua atuação foi juntado no procedimento administrativo instaurado na OAB, diante da representação da vítima. Não juntou aos presentes, contudo, cópia do mencionado contrato. Suspeita a desídia, considerando-se que a ré já foi condenada em data anterior por outros dois crimes de apropriação indébita - cf. certidões de objeto e pé juntadas às págs.696 e 700, e ainda responde a outros quatro processos por tal delito - certidões de objeto e pé às págs.701/702, 704, 705 e 712).

Prosseguiu: Enrique pagaria 10 parcelas, no valor de 1.500,00 cada, a título de honorários advocatícios, o que não ocorreu. O inquérito policial mencionado tramitou 'por volta de 2006'.

Aproximadamente 18 a 24 meses depois, foi procurada novamente por Enrique para defesa do filho dele, preso por tráfico de droga. Acompanhou o procedimento desde a prisão em flagrante até o término do processo criminal. Petherson foi absolvido e a sentença foi mantida em Segunda Instância. Foi combinado o mesmo valor de 15 mil reais, em novo contrato. A vítima pagaria 10 parcelas de 1500,00, o que também não ocorreu (na resposta à acusação, a ré havia informado que os honorários advocatícios foram avençados em R\$8.000,00, cf, págs.403/404).

Depois disso, por volta de 2009, ajuizou ação contra a Motorola, porque a vítima comprou um aparelho celular e teve problema. A Motorola chegou a trocar o bem. Não foi feito outro contrato formal, mas ficou combinado com a vítima que, em caso de êxito, receberia 20% sobre o valor final a título de honorários advocatícios. Como não houve êxito financeiro, mas troca do aparelho celular, fez outro acordo com a vítima, mas não recorda o valor que deveria ter sido pago por Enrique.

Na mesma época, ajuizou ação contra a Telefônica em benefício da vítima. Diante do acolhimento do pedido, a própria vítima efetuou o levantamento do valor no Banco do Brasil. Não pagou, contudo, os honorários advocatícios (havia sido combinado 20% do

êxito, sem contrato formal). Não lembra o valor devido pela vítima.

Esse valor de honorários advocatícios também foi ajustado em ação ajuizada pela vítima contra a Caixa Econômica Federal, em 2009 ou 2010. Houve substabelecimento para um advogado do sindicato e Enrique não efetuou nenhum pagamento.

Fez um levantamento do total devido pela vítima a título de honorários advocatícios. Alcançava 40 mil reais, aproximadamente.

Finalmente, disse ter sido procurada por Enrique para ajuizamento de ação trabalhista, mas apenas prestou consultoria e não atuou.

O único valor que a vítima pagou corretamente, a título de honorários advocatícios, foram as três primeiras parcelas referentes ao benefício da ação do INSS, quando concedida a tutela antecipada.

Recebeu o valor da ação previdenciária mencionada na denúncia em 2015, referente 'aos atrasados' devidos a Enrique pelo INSS, usando a quantia para pagamento das dívidas da vítima nos termos acima mencionados, operando-se a compensação avençada. Quando tomou conhecimento de que o valor havia sido creditado em sua conta, contatou Enrique (que também tinha e-mail cadastrado no sistema Push da Justiça Federal e estava ciente do crédito), que concordou com a compensação. Informou à vítima que ainda restava valor a ser quitado pelo cliente (aproximadamente R\$8.000,00).

Não teve mais contato com a vítima.

O filho da vítima continuou sendo seu cliente do escritório e estranhou a atitude do pai, após representação na OAB e lavratura de B.O, pois a alegada compensação era de seu conhecimento.

A versão defensiva, contudo, ficou isolada nos autos pelo mais da prova colhida em instrução.

A acusada não comprovou por qualquer adminículo de prova a sua versão.

Não juntou aos autos documentos aptos a demonstrar: a) os honorários advocatícios avençados em relação às outras ações mencionadas; b) o ajuizamento de todas as ações ou o acompanhamento dos feitos administrativos citados em sua defesa e c) o acordo com a vítima para utilização da verba previdenciária como compensação pelos alegados (mas não comprovados) serviços advocatícios que teriam sido prestados em outros feitos.

A alegação inicial (na resposta à acusação, pois no interrogatório judicial a ré alterou a versão e afirmou que não formalizou o acordo, operado verbalmente) de que a documentação pertinente foi destruída em enchente que atingiu o escritório da acusada também não vem acompanhada de nenhum dado concreto a embasá-la. A perda de tantos documentos relevantes (na resposta à acusação sugere-se destruição geral do arquivo) sequer (ausente nos autos) foi formalizada por documento apto a formalizá-la. Estranha-se, outrossim, que a acusada não tenha alegado e/ou provado a busca de tais documentos (histórico de sua vida profissional e título para cobrança de honorários) mediante contato com clientes ou qualquer outra forma idônea e necessária para demonstração do evento utilizado como álibi.

Quanto à posterior modificação da tese defensiva acerca da natureza do acordo (de escrito para verbal), cumpre destacar que a vítima foi firme ao afastar ter realizado com a acordo verbal para compensação alegada pela defesa.

Com efeito, a versão defensiva, a par de não acompanhada de prova, ônus que à ré

cabia (CPP, art.156), foi afastada pelas declarações da vítima Enrique, que sob o crivo do contraditório confirmou a dinâmica dos fatos relatada na fase extrajudicial, com coerência:

Contratou a ré para ajuizar processo em face do INSS. Pagou os honorários advocatícios para o ajuizamento da ação, consistente no valor dos três primeiros benefícios previdenciários (confirmou os valores informados nos recibos juntados às págs.30/32). Também ficou estipulado no contrato que a ré reteria 30% do valor final, bruto, pago pelo INSS, a título de honorários advocatícios. Não houve, por qualquer modo, acordo posterior para modificar o ajuste inicial.

Não havia recebido informação alguma sobre o processo, cujo resultado demorava, e procurou o INSS. Cristiane não havia lhe informado o número do processo. Soube que o pedido tinha sido julgado procedente e o valor levantado pela advogada tinha alcançado quase 29.000,00.

Foi orientado a se dirigir ao Fórum para receber informações e confirmou que a ré havia se apropriado de seu dinheiro. A acusada recebeu os valores sem lhe informar e nada lhe repassou.

Procurou a ré para conversar sobre o que havia descoberto, mas ela, sem lhe fornecer motivo, disse que 'não tinha nada para receber'. Não aceitou qualquer acordo. Dirigiu-se à OAB e foi orientado a registrar boletim de ocorrência.

Na época, estava desempregado, com dívidas e prestações da casa para pagar. Precisava do dinheiro. Teve depressão.

Não possuía dívidas com a ré.

A ré prestou serviços advocatícios em ação ajuizada contra a Telefônica. Havia sido efetuada ligação para os Estados Unidos em telefone registrado em seu nome. Valor alto. A acusada disse que receberia R\$5.000,00, acolhido o pedido. Combinou verbalmente com ela que esse valor seria o pagamento da defesa que ela efetuava na ação penal ajuizada contra o seu filho, por tráfico de droga. Petherson, usuário de substância entorpecente, foi absolvido. A ré ficou com o valor de R\$ 5.000 reais, a título de honorários advocatícios.

Também fez uma consulta sobre o ajuizamento de ação contra a Motorola. A acusada orientou que fosse ao Procon. Assim fez e resolveu no Procon a pendência, administrativamente. Cristiane não praticou qualquer ato e nenhum funcionário do escritório da ré o acompanhou ao Procon.

Não contratou a ré para atuar em ação de execução de alimentos ajuizada em face de seu filho Petherson. Cristiane foi contratada diretamente por seu filho e não tem conhecimento do avençado, apenas que os honorários advocatícios foram pagos por Petherson.

Não contratou a acusada para atuar em sua defesa em inquérito policial da Polícia Federal. Na época, estava afastado pelo INSS e um colega de trabalho indicou determinada pessoa para que tentasse a sua aposentadoria. O depoente havia tido um derrame e trombose venosa profunda. Foi consultar essa pessoa, não se recorda ao certo o nome, acredita que 'Otacílio'. O indivíduo pediu-lhe um cheque caução. Ocorre que tal indivíduo estava envolvido em fraude contra o INSS e a Polícia Federal o intimou por ter encontrado tal cártula em poder do sujeito. A acusada não o acompanhou à sede da Polícia Federal, onde prestou declarações única vez, sozinho, e tampouco prestou qualquer serviço advocatício neste caderno investigatório.

Como reiteradamente se tem decidido, a palavra da vítima, se coerente e uniforme,

deve merecer integral acolhimento. É o que se vê patenteado no caso em tela.

O filho da vítima, Petherson Rakam Fernandes Torres, confirmou o relato de Enrique:

Quando foi preso em flagrante (tráfico de droga), o seu pai contratou os serviços advocatícios da ré. Para pagamento dos honorários, acordaram verbalmente que o dinheiro que Enrique receberia na ação ajuizada em face da Telefônica - R\$5.000.00 - ficaria com a ré. Assim foi feito.

Não tem conhecimento dos demais serviços prestados pela ré ao seu pai e os ajustes que realizaram.

Posteriormente, quando precisou de serviços advocatícios (ações relacionadas ao seu filho, que tramitaram na Vara de Família), procurou a acusada sem a intermediação de seu pai, efetuando diretamente o pagamento dos honorários advocatícios avançados, de seu 'próprio bolso' (a ré cobrou pouco mais de 200 reais por ida ao Fórum. Pagava em espécie no escritório). Pagou integralmente pelo serviço prestado por Cristiane. Não restou dívida.

A prática do delito pela ré ficou demonstrado pelo mais da prova colhida em instrução.

As declarações das pessoas arroladas pela defesa não tiveram o condão de afastar o panorama probatório, francamente incriminador. Próximas da ré, evidentemente procuraram beneficia-la.

A testemunha Luciano, ex-marido de Cristiane e pai do filho dela, foi ouvido sem compromisso. Narrou que, na época dos fatos, trabalhava no 'administrativo' do escritório, fazendo a contabilidade.

A vítima era amiga pessoal da ré e a contratou para prestar serviços advocatícios em alguns processos. Citou ação criminal em face da própria vítima e filho dela, ações contra a Motorola e Caixa Econômica Federal (citou outros processos genericamente, sem identifica-los). Enrique não efetuou o pagamento de nenhum honorário advocatício contratado.

Em relação a todas as ações ajuizadas por Enrique e em favor do filho dele foi elaborado contrato versando sobre os honorários advocatícios (a própria ré afastou tal alegação em seu interrogatório judicial).

Cobrou pagamento dos honorários advocatícios devidos pela vítima, que dizia ter feito acordo com a acusada, ou seja, Cristiane ficaria com o valor que receberia na ação ajuizada em face do INSS, como forma de compensação.

Em razão da amizade entre ré e vítima Enrique, não foi elaborado termo de acordo sobre este específico ponto. Foi verbal (estranha-se a alegação do informante. Ora, malgrado estipulado em contrato o valor dos honorários advocatícios de cada ação, como afirmou, malgrado a amizade entre vítima e ré, apenas em relação a este ponto específico e relevante - compensação alegada - a ré teria de descuidado, deixando de formalizar o acordo).

O informante não soube, contudo, indicar o valor específico dos honorários advocatícios devidos em cada ação. Aduziu que cobrava valor de aproximadamente R\$ 1.500/1600 mensalmente, mas não soube informar o total. Declarou 'acreditar' que a quantia devida pela vítima alcançava 40 mil reais.

A testemunha ainda afirmou que, ao tomar conhecimento do levantamento do valor da

quantia previdenciária indicada na denúncia, a vítima 'simplesmente esqueceu' o combinado (não é crível a alegação, consoante acervo probatório). Completou: A vítima não foi ao escritório de Cristiane, de modo que não conseguiu sequer discriminar os valores a Enrique, explicando o ocorrido.

A testemunha Celso Belmiro Beijamin declarou que trabalhava na recepção do escritório onde Cristiane atuava (não conseguiu, contudo, informar o período). Enrique, amigo dela, procurou a ré para atuar em diversas ações (que não soube especificar. Lembrou da defesa feita por Cristiane no processo criminal ajuizado contra o filho de Enrique e de outro referente a um aparelho celular), mas declarou que não tinha condições de pagar os honorários advocatícios, afirmando que a advogada poderia usar o valor que receberia do INSS para 'abater' a dívida.

Não soube informar, contudo, o valor dos honorários advocatícios e se havia formalização do ajuste em contrato.

Genéricos, os informes não contribuíram para dar credibilidade à versão defensiva.

Claudinei Iori afirmou que também trabalhou como recepcionista no escritório, efetuando atendimento telefônico e cobrança de pagamento de honorários advocatícios.

Afirmou que Enrique era amigo de Cristiane, que atuou em favor dele em vários processos (recordou apenas acompanhamento de investigação na Justiça Federal, ação penal ajuizada em face do filho de Enrique e acompanhamento do caso da Motorola no Procon).

Sem dinheiro para pagar os honorários advocatícios avençados em tais ações, a vítima, quando questionada, dizia que havia combinado com Cristiane a quitação da dívida mediante compensação com o valor que receberia do INSS.

Normalmente os honorários advocatícios eram ajustados em contrato. Por ser Enrique pessoa próxima da ré, os ajustes foram verbais.

Não recordou, contudo, qual o valor total da dívida de Enrique ou se havia crédito para abater.

O depoimento da testemunha de defesa, sem dados específicos sobre ações e respectivos honorários, não teve o condão de afastar o panorama probatório, francamente incriminador.

Finalmente, Zoraide Pereira, amiga da ré, afirmou que também trabalhou como recepcionista no escritório, efetuando cobrança de honorários advocatícios devidos pelos clientes. Enrique, pessoa próxima da acusada, dizia que o dinheiro que receberia na ação ajuizada em face do INSS seria usado para pagamento de honorários advocatícios devidos em outras ações.

Chama atenção o fato de que a ré, única advogada do escritório, tenha tido inúmeros recepcionistas no período (inexiste registro para comprovar o vínculo empregatício) e nenhum deles se recorde, embora tenham afirmado inúmeras cobranças em face da vítima Enrique, o período exato em que trabalharam para Cristiane ou das ações e os valores devidos a título de honorários advocatícios. Ofertaram genéricas afirmações.

O pai da ré, Flodoaldo Neto de Novais, foi ouvido como informante:

Conhece a vítima Enrique há mais de 30 anos. Trabalharam juntos. Soube que Cristiane foi contratada em duas oportunidades pela vítima: "Tirou o filho dele da cadeia" e atuou em ação ajuizada contra o Banco do Brasil. Enrique comentou que os honorários seriam acertados quando saísse o dinheiro no 'processo do INSS'. Nesta

ocasião, a vítima também teria comentado que Cristiane havia prestado serviço em favor dele na Polícia Federal. Não sabe o valor devido.

Os depoimentos das testemunhas e informantes arrolados pela ré passaram de imediato a impressão de que oriundos de uma única fonte, artificialmente composta e até fraudulentamente multiplicada. Não convenceram o Juízo.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do crime imputado à acusada, afastada a legitimidade da retenção do valor pela ré.

Não houve mero ilícito civil.

É pacífico na doutrina e jurisprudência que o pressuposto material do crime de apropriação indébita é a existência da posse ou detenção legítima de coisa móvel alheia pelo sujeito ativo.

E, segundo Júlio Fabbrini Mirabete:

“A origem legítima da posse é, evidentemente, uma relação obrigacional quer derive de contrato, testamento, de ordem de autoridade, quer de disposição legal” (in Manual de Direito Penal – Parte Especial – vol. II, São Paulo: Atlas, 2003, p. 285).

Assim, o pressuposto material do delito em questão mostra-se incontestado. Ficou demonstrado que a ré não apenas englobou os valores dos honorários devidos, mas também a parte que cabia à vítima, na ação previdenciária por ela movida.

No presente caso, o dolo da agente mostrou-se evidente, não havendo, pois, falar-se em atipicidade da conduta.

Nesse sentido: “Com base no art. 168, § 1º, III, do CP, responde por apropriação indébita o advogado que levanta quantia pertencente a seu cliente, e, injustificadamente, não lhe encaminha, imediatamente, o numerário, ainda que posteriormente venha a restituir o dinheiro” (STJ RT760/574).

Trata-se de crime instantâneo, cujo resultado é imediato, não havendo prolongamento da conduta no tempo, razão pela qual consumado restou.

Nesse sentido:

“A consumação do delito de apropriação indébita ocorre, quando o agente transforma a posse ou a detenção da coisa em domínio” (STJ – Rel. Min. JOSÉ CÂNDIDO – RJD 16/227).

“O momento consumativo do crime de apropriação indébita e, pois, de aperfeiçoamento do tipo, coincide com aquele em que o agente, por ato voluntário e querido, inverte o título da posse exercida sobre a coisa, passando a dela dispor como proprietário. E o crime, uma vez operada a inversão, está perfeito e acabado.” (TACRIM/SP – Rel. CANGUÇU DE ALMEIDA – JUTACRIM 88/400).

Restou demonstrado que a ré efetivamente inverteu o ânimo da posse mantida em relação ao dinheiro da vítima, o tratando como se seu fosse, e que agiu imbuída de dolo.

Portanto, presentes as elementares do crime de apropriação indébita, não merece guarida o pedido defensivo de desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 345 do Código Penal.

Restou caracterizada, ainda, a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso III, do §1º, do artigo 168 do Código Penal, isso porque os valores só puderam ser levantados em razão de a ré ser advogada que patrocinava a ação, devendo ser a pena majorada nos termos do tipo legal.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA - Advogada que se apropriou de valores pertencentes à cliente, cuja posse detinha em razão da profissão - Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente - Recurso desprovido". (TJSP; Apelação 0002127-26.2015.8.26.0699; Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto de Pirapora - Vara Única; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro: 05/02/2018).

Portanto, a ré realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis à acusada. Já foi condenada irrecorrivelmente por crimes idênticos e anteriores (condutas praticadas em 2011) ao apurado nestes autos (autos nº 3009370-55.2013 - 5ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. A condenação transitou em julgado no curso deste processo em 19.02.2018. E autos nº 0022711-39.2011 - 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. A condenação transitou em julgado no curso deste processo em 12/06/2019, cf. certidões criminais de objeto e pé juntadas às págs.696 e 700).

Também ostenta condenação pelo crime previsto no artigo 298 do Código Penal (fato anterior - 2009 - ao apurado nestes autos. Condenação com trânsito em julgado em 2016).

Nessa linha:

"O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes" (HC 171.212/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 20/08/2015).

Ostenta condenação em Primeiro Grau também pelo crime previsto no artigo 168, §1º, inciso III, do Código Penal, nos autos nº 0016419-96.2016 - 2ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo (pág.704 - pendente julgamento do recurso interposto pela defesa) e foi denunciada pela prática de idêntico delito em outros processos ainda em andamento em Varas Criminais desta Comarca de São Bernardo do Campo (certidões de objeto e pé às págs.701/702, 705 e 712).

Condenações sucessivas pelo crime de apropriação indébita demonstram que a ré fez de ação criminosa o seu meio de vida, sendo maior a censurabilidade de sua conduta, circunstância que deve ser considerada nos exatos termos dos artigos 59 do Código Penal.

As consequências do crime também não podem ser olvidadas, pois a ré se apropriou de relevante valor - R\$ 28.978,13 (valor total do dinheiro devido pelo INSS à vítima) - mormente no ano de 2015, causando maior prejuízo patrimonial à vítima.

Sobressai-se, na hipótese dos autos, maior censurabilidade na conduta da agente. Assim, diante das circunstâncias e consequências acima ponderadas, elevo a pena base em 1/4, o que perfaz 01 ano e 03 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Não incidem agravantes ou atenuantes.

Incide a causa de aumento prevista pelo artigo 168, §1º, inciso III, do Código Penal, razão pela qual elevo a reprimenda em 1/3, fixando-a em 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena.

O valor do dia-multa, ante a aparente situação econômica da acusada, será calculado no valor unitário mínimo e deverá ser atualizado nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (RT 628/338).

Considerando a ausência de violência e grave ameaça à pessoa e que a ré é tecnicamente primária, excepcionalmente fixo o regime ABERTO para início de cumprimento de pena, adequado à consecução das finalidades da sanção penal. Não estão presentes os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, institutos baseados na autodisciplina e destinados a quem não se dedica à práticas criminosas. Não é o que se vê patenteado nos autos.

Desfavoráveis as condições subjetivas da acusada, que ostenta processos em andamento e condenações irrecorríveis pelo mesmo crime, por fatos anteriormente praticados, o que demonstra que o delito comprovado nestes autos não tratou de mero desvio na vida da acusada.

A conduta social apresentada pela agente demonstra que os institutos despenalizadores não são medidas socialmente recomendáveis e não atenderiam às finalidades da sanção penal, constituindo incentivo à reiteração da conduta e impunidade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar a ré CRISTIANE LEANDRO DE NOVAIS, CPF nº 245.488.188-80, como incurso no artigo 168, §1º, inciso III, do Código Penal, razão pela qual a CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo, conforme retro detalhado.

A ré respondeu ao processo solta, sem percalços. Considerando a pena fixada acima e ausentes os requisitos da custódia cautelar, permito o recurso em liberdade.

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, consoante o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois não houve requerimento expresso na denúncia. A vítima poderá ser valer das vias idôneas para precisar o valor e ser reparada do prejuízo, caso queira.

Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se o nome da acusada no rol dos culpados.

Custas pelo réu, no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, § 9º, "a", da Lei 11.608/03.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 04 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA